

0005067-97.2016.8.26.0417

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Magistrado: HEITOR MOREIRA DE OLIVEIRA
Comarca: Paraguaçu Paulista
Foro: Foro de Paraguaçu Paulista
Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... requereu a desclassificação do tráfico de drogas para o art. 28, caput, da Lei. 11.343/06 e que seja absolvido quanto ao delito previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação penal proposta contra Michel de Santana pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A pretensão punitiva estatal é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paraguaçu Paulista

Foro de Paraguaçu Paulista

1ª Vara

Avenida Siqueira Campos, 1429, Paraguacu Paulista-SP - cep 19700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0005067-97.2016.8.26.0417 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0005067-97.2016.8.26.0417

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Termo Circunstanciado - 01/2015 - DEL.POL.PLANTÃO PARAGUAÇU

PTA, 01/2015 - Delegacia de Polícia de Paraguaçu Paulista

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHEL DE SANTANA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HEITOR MOREIRA DE OLIVEIRA

Vistos.

MICHEL DE SANTANA e BRENDON FELIPE BARBOSA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, porque, supostamente, no dia 08 de janeiro de 2015, por volta das 01h15, na Rua Doutor Lauro Ferreira Braga, nº 505, Barra Funda, nesta cidade e Comarca, os réus, agindo em concurso e com unidade de designios, traziam consigo, para posterior entrega a consumo de terceiros, 01 (uma) porção de maconha, pesando aproximadamente 0,5 g (quinhentos miligramas) e 02 (dois) pinos de cocaína, com peso aproximado de 0,5g (quinhentos miligramas), conforme laudo de constatação provisória de fls. 28/29, substancia que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda que, ao menos até a data acima, MICHEL SANTANA e BRENDON FELIPE BARBOSA PINTO, associaram-se, para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Ocorreu o desmembramento do processo em relação ao corréu Michel de Santana (fl. 174).

A denúncia foi recebida em 08 de outubro de 2018 (fl. 179).

Devidamente citado, o réu ofertou defesa prévia (fls. 214/223).

Durante audiência de instrução e julgamento, foram colhidos depoimentos das testemunhas. Foi decretada a revelia do réu (fl. 251).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal para condenar o réu nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e absolver quanto ao artigo 35, caput, da Lei 11.343/06.

A defesa, por sua vez, requereu preliminarmente a atipicidade da conduta, requereu a desclassificação do tráfico de drogas para o art. 28, caput, da Lei. 11.343/06 e que seja absolvido quanto ao delito previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação penal proposta contra Michel de Santana pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

Consta na denúncia, supostamente, os denunciados associados com o fim de praticar o tráfico de drogas, na data dos fatos, desenvolviam a atividade ilícita no supramencionado local.

Ocorre que policiais militares, após receberem denúncia com características físicas e de vestimentas dos autores da traficância, se dirigiram ao local e avistaram os denunciados, com as próprias descrições da denúncia, sendo que ao notarem a presença da viatura policial, MICHEL dispensou dois pinos de cocaína que trazia consigo e ambos rumaram para o interior de um bar.

Em abordagem, localizaram no bolso de BRENDON, uma porção de maconha e apreenderam os dois pinos de cocaína dispensados por MICHEL.

Pela variedade de droga apreendida, forma de acondicionamento, precisão da denúncia anônima, bem como pelas demais circunstâncias da prisão em flagrante, patente a prática do comércio ilícito de entorpecentes e de associação ao tráfico pelos denunciados.

Analisando as provas coligidas nos autos, e em harmonia com a sentença do processo 000135-03.2015.8.26.0417, entendo que é o caso de desclassificação da conduta do acusado para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas.

A materialidade do crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 restou comprovada pelo termo circunstanciado (fls. 07/09), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 10), pelas fotografias (fls. 13/14), pelo laudo de constatação (fls. 28/29), laudo exame químico-toxicológico (fls. 53/54), pelos termos de depoimento em solo policial (fls. 37 e 41), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também é certa e recai sobre o réu.

Senão, vejamos a aprova oral colhida em audiência.

Em solo policial, a testemunha Andreia Aparecida de Lima Crystal relatou que: "É policial militar e desempenha suas funções nesta cidade. Confirma na íntegra sua versão acostada a fl. 04 do presente feito. Esclarece que a porção de maconha foi encontrada no bolso de Brendon Felipe Barbosa Pinto e a porção de cocaína o outro indivíduo jogou no chão, fato presenciado pela depoente e o policial Castilho, inclusive quando os dois avistaram a viatura saíram correndo, entrando no interior do bar". (fl. 37) Em juízo, contou que: "acredita que o caso foi em uma lanchonete, se for o caso que está pensando, estavam na barra funda, estavam patrulhando e quando viraram, os acusados entraram correndo para dentro, e o Cabo Castilho na época, hoje já é sargento, abordou um que estava com droga no bolso e outro jogou a droga fora, era cocaína e o outro estava com maconha. Que não se recorda se receberam denúncia que os dois estariam traficando. Não se recorda se eles estavam com dinheiro. Que não lembra se os conhecia, trabalhava mais com proerd, com criança. Que no dia dos fatos quem abordou Michel foi o Arthur, e ele encontrou maconha com um e o outro jogou a cocaína que também, foi encontrada. Que no dia eram dois acusados. Que não se lembra se Michel falou que era usuário de maconha". Em solo policial, a testemunha Arthur Celso Castilho Prado relatou que: "É policial

militar e desempenha suas funções nesta urbe. Que afirma na íntegra sua versão acostada a fl. 03 do presente feito. Informa que a porção de maconha foi encontrada no bolso da pessoa de Brendon Felipe Barbosa Pinto e a porção de cocaína o outro indivíduo jogou no chão, fato presenciado pelo depoente e a policial militar Andréia. Por fim, deseja esclarecer que quando os dois avistaram a polícia militar saíram correndo, entraram no interior do bar". (fl. 41) Em juízo, contou que: "se recorda é que estava em patrulhamento com a soldada Andreia pela barra funda, quando se deparam com dois indivíduos, defronte com um bar, momento que tentaram evadir-se, um correu e dispensou uma porção de cocaína salvo engano e o outro que é o Brendon, ele foi detido e com ele foi encontrado uma porção de maconha. Que no local já houve outras práticas ilícitas, mas não se recorda se nesse dia houve denúncia. Que não se recorda da fisionomia de Michel, o Brendon se recorda porque já abordou ele outras vezes, porém nada de ilícito foi encontrado com ele. Que não se recorda da fisionomia de Michel, mas ele foi o indivíduo que dispensou algo no chão, e após verificar foi constatado que era cocaína, mas não se recorda se no bolso dele ou nas vestes havia algo. Não se recorda se Michel afirmou que era usuário de droga. Não se recorda se Michel estava com dinheiro ou algo desse tipo. Que não se recorda quem foi o indivíduo que correu para o bar, acredita que foi Michel e ele foi abordado dentro do bar".

Em juízo, a testemunha Gleice Barbosa dos Santos contou que: "Não conhece Michel. Que Brendon conhece de vista. Quando a polícia chegou em seu estabelecimento, a declarante estava para o lado de dentro do balcão, só viu a hora que eles entraram e a polícia já chegou atrás deles, a polícia pegou eles, levou para fora e ficou com lá com eles. Não viu se a polícia achou algo, nem droga e nem dinheiro, porque estava dentro do balcão e o balcão é meio alto. Não viu se Michel dispensou algo antes de entrar no bar, a declarante estava de costas limpando o freezer e até tomou um susto quando eles entraram com tudo. Não sabe se Michel é usuário de drogas. Que na época havia câmera no bar, e seu esposo disse que havia passado as imagens para o policial, a declarante nem sabe mexer com câmera".

Em juízo, a testemunha Maicon Roberto dos Santos Souza contou que: "não conhece Michel. Que pelo que se recorda já foi na audiência do Brendon, se ver ele sabe quem é. Que ficou sabendo do ocorrido porque na intimação viu que estava escrito Castilho e Andréia, e a única ocorrência que teve com eles foi sobre esse assunto. Que no dia estava sentado na frente do bar, o bar era de sua esposa e viu um pessoal na esquina na Padre Anchieta, uns meninos, e de repente esses meninos vieram e adentraram ao bar, e no que eles entraram, a polícia passou e já parou e foi aí que ocorreu a abordagem. Que lembra que com Michel não foi encontrado nada, porém perto do freezer, perto da entrada da lanchonete sim, no chão. Não viu se Michel jogou no chão, porque foi tudo muito rápido. Ficou com medo de dar problema para sua esposa o fato da droga ter sido achada perto do freezer, na entrada, havia uma câmera na lanchonete, o declarante pegou a gravação dela e passou para o Cabo Castilho, e por mais que a imagem da câmera fosse ruim, dava para ver que alguém jogou algo naquele local. Não viu se a polícia encontrou dinheiro com Michel. Não sabe se Michel é usuário, não conhece ele e não pode dizer nada sobre ele".

Pois bem.

• Art. 33, caput, Lei 11.313/09

Analisando detidamente o conjunto probatório, entendo que não ficou demonstrado que as drogas apreendidas seriam destinadas a terceiros.

Os policiais ouvidos em juízo narraram de forma sucinta, isso devido a decorrência do tempo da data dos fatos, que o acusado Michel dispensou a cocaína no chão, enquanto o outro acusado estava com uma porção de maconha. Não se recordaram de ter recebido denúncia anônima quanto ao suposto tráfico praticado pelo acusados. Contaram que não conheciam Michel de Santana, acrescentando ainda que não se recordam de sua fisionomia.

Vale lembrar que as afirmativas feitas pelos agentes policiais têm a presunção juris tantum de serem verdadeiras, posto que estão à serviço do Estado para garantir a segurança do cidadão e manter a ordem pública, cabendo a quem alegar eventual falsidade ou conduta ilícita da parte dele, prová-la ou, ao menos, trazer ao juízo indícios coerentes da dita irregularidade, o que não aconteceu no presente

caso.

"PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimentos de policiais - Admissibilidade-Inexistência de suspeição e contradição - Hipótese em que os testemunhos são harmoniosos, claros e precisos - Recurso não provido. Os depoimentos de policiais que se apresentarem harmoniosos, claros e precisos não podem sofrer desmerecimento como prova criminal". (Apelação Criminal n. 173.078-3 - Guarujá - Relator: FRANCODE GODOI- CCRIM 3 - V.U. - 12.12.94)

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC nº 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello.)

A testemunha Gleice, em nada acrescentou, apenas soube informar que os acusados e a polícia entraram em seu bar, nada mais soube dizer, pois estava de costas limpando o freezer. Acrescentou que não conhece Michel.

O relato da testemunha Maicon foi de encontro com a versão dos policiais, disse que nada foi encontrado com Michel, no entanto, foi encontrada droga dentro da lanchonete, próximo ao freezer, e ao olhar na câmera de segurança foi possível visualizar que alguém jogou a referida droga lá. Acrescentou que não conhece Michel.

Diante dos relatos colhidos em audiência, não resta dúvida de que o acusado dispensou o entorpecente, em nada implica que não tenha sido encontrado com o réu, razão pela qual nego a preliminar de atipicidade alegada pela defesa.

Contudo, a cocaína encontrada no chão trata-se de dois pinos, com peso aproximado de 0,5 gramas, sendo um volume muito pequeno para presumir destinar-se ao tráfico. Ainda, os policiais não conheciam o acusado, demonstrando não estar envolvido no meio ilícito, em específico na traficância de drogas.

Por essa razão, não se evidenciou a prática de tráfico, todavia, caracterizado o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Até mesmo para manter a coerência com o processo 000135-03.2015.8.26.0417 no qual desclassificou a conduta do acusado Brendon Felipe Barbosa para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, tendo em vista que ocorreu no mesmo sentido fático. De outro giro, observe-se que o crime descrito no art. 28 é de perigo e para a sua consumação basta apenas o porte do entorpecente, nada relevando a quantidade de droga em poder do usuário. Logo, não se aplica à espécie o princípio da insignificância, isso porque a pouca quantidade de entorpecente não torna atípica a conduta, haja vista que a criminalização decorre das propriedades psíquicas da droga, do risco social e para a saúde pública que representa, e não propriamente em razão dos efeitos que seriam produzidos em cada caso concreto (STF, RT 651/372, RTJ 122/186, 119/453, 119/874; STJ, JSTJ 16/202; TJSP, RJTJSP 133/294, 107/445, 105/447, 104/459; RT676/286, 615/275, 613/316, 601/305, 569/306).

No mesmo norte, ainda, não há que se falar em descriminalização do crime de porte de entorpecentes para consumo pessoal, consoante reiterado entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do qual destaco:

"APELAÇÃO. USO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICAM A PRÁTICA DO CRIME DE USODE ENTORPECENTES. NÃO HOUE DESCRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA DO ART.28, "CAPUT", DA LEI N. 11.343/06. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...) 3. Não há que se falar em descriminalização da conduta de posse de substância entorpecente, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, que é direito difuso por excelência e que se sobrepõe à liberdade individual daquele que consome substâncias entorpecentes, vale

dizer, sem ferir o direito à intimidade, previsto no art. 5º, X, da CF. Inteligência da Doutrina e da Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Por sinal, em que pese o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, ter se manifestado pela existência de Repercussão Geral, a tese da constitucionalidade do art. 28, da Lei n. 11.343/06, ainda não foi dirimida, devendo prevalecer o entendimento consolidado no âmbito deste tribunal de Justiça até o julgamento final da matéria pelo Pretório Excelso, no sentido da constitucionalidade do crime de uso de substância entorpecente.” (Apelação Criminal 023602-49.2011.8.26.0482, julgada em 26/11/2015).

Pelos argumentos acima entendo que não é caso de se reconhecer a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Comprovadas autoria e materialidade e levando-se em conta os elementos concretos do fato, entendo que deva ser aplicada a pena de advertência ao acusado. Afinal, trata-se de réu primário e que não ostenta maus antecedentes.

- Art. 35, caput, Lei 11.343/06

Inicialmente, a conduta do acusado não se enquadra como tráfico de drogas. E, além disso, não ficou atestada a estabilidade e permanência entre os acusados. Aliás, esta é a diferença entre o crime mencionado e o simples concurso de agentes. Nesse sentido, é a jurisprudência remansosa do C. STJ e do STF, senão vejamos:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/06. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MERA ATUAÇÃO EM COMUM NA PRÁTICA DE UM DELITO. AUSÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. ATIPICIDADE RECONHECIDA. MINORANTE PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA NOVA LEI DE TÓXICOS, FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE, EM TESE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. 1. Paciente condenada, em sede de apelação, como incurso no arts. 33 e 35, c.c. 40, inciso III, todos da Lei n.º 11.343/06, à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado, porque, no dia 23 de outubro de 2008, foi presa em flagrante delito por pagar à corré para entregar uma porção de maconha, com massa de 78,67 g, a seu irmão detento, dentro do Presídio. 2. O acórdão impugnado entendeu pela desnecessidade do ânimo associativo permanente, reconhecendo que a associação para a prática de um crime seria suficiente para condenar a acusada como incurso no art. 35 da Lei n.º 11.343/06. Entretanto, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para configuração do tipo de associação para o tráfico, necessário estabilidade e permanência na associação criminosa. Atipicidade reconhecida. 3. Reconhecida a atipicidade da conduta de associação eventual para o tráfico de drogas, o édito condenatório perdeu seu único argumento para negar à Paciente a causa de diminuição de pena inserta no § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na medida em que, considerou o acórdão impetrado que a condenada, ora Paciente, não preenche os requisitos legais para a concessão da benesse por integrar associação criminosa. 4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n.º 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o disposto no art. 33, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 5. Afastado o óbice previsto na Lei de Drogas, pela Resolução n.º 05/2012, do Senado Federal, deve o Juízo competente analisar se o condenado preenche ou não os requisitos para a obtenção da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, à luz do art. 44 do Código Penal. 6. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para cassar a condenação no tocante ao crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/06 e determinar que o Eg. Tribunal de Justiça a quo proceda ao exame do preenchimento ou não dos requisitos necessários à concessão da minorante no prevista no § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e, consequentemente, do regime adequado de cumprimento de pena e da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Por se encontrar em idêntica situação processual, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, estendo os efeitos do julgado à corré LUCELINE DA SILVA PAIVA.(STJ - HC: 248844 GO 2012/0148550-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, j. em: 21/05/2013, T5 - QUINTA

TURMA)

Por isso, impõe-se a absolvição no tocante à imputação da prática do crime descrito no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

a) ABSOLVER o acusado MICHEL DE SANTANA, qualificado nos autos, da imputação da prática prevista nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, o que faço com fulcro no artigo 386, VII, do CPP;

b) CONDENAR o acusado MICHEL DE SANTANA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a PENA DE ADVERTÊNCIA.

Caso tal providência ainda não tenha sido tomada, determino a destruição do entorpecente apreendido, preservando-se, nos termos do artigo 32, § 1º, da Lei 11.343/06, amostras necessárias à preservação da prova, considerando ulterior necessidade de realização de novos exames.

Expeça-se certidão de honorários nos termos do convênio DPE/OAB (fl. 210).

Com o trânsito em julgado, promovam-se os expedientes necessários para o cumprimento da pena imposta e, após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.I.C.

Paraguacu Paulista, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA